

释法抑或造法： 由刑法历次修正引发的思考

杨 柳*

内容提要 刑法历次修正表明,我国刑法正从“厉而不严”走向“严而不厉”。然而,刑法修正所追求的目标应是法网严密,即“疏而不漏”。作为严密刑事法网的不同进路,释法并不绝对排斥造法,但在位阶上应当优先于造法使用。频繁犯罪化的刑事造法本质上是刑法工具思维和刑法功能泛化的体现,对之应保持警惕并予以限制。在社会主义法律体系基本建成的背景下,“立法中心主义”应向“释法中心主义”转变。

关键词 刑法修正 释法 造法 严而不厉 疏而不漏

一、刑法历次修正的基本梳理:从“厉而不严”到“严而不厉”

自1997年《刑法》颁布之后,从1999年至今的短短十余年间,我国已经颁布了九部刑法修正案,这是一段我国刑法修正极为频繁的时期。纵观迄今为止的历次刑法修正,主要表现为两大特征:

(一) 刑法历次修正的犯罪化趋向

要论及历次刑法修正的基本特征,“犯罪化”当仁不让的是迄今为止刑法修正的“主线”。如果实现严密刑事法网之意图,犯罪化的刑事立法无疑是最为直接、有效的手段。对于大多数人而言,直觉上会认为“罪名越多则刑事法网越严密”,这也成为立法者以“犯罪化”作为刑法修正诉求的主要动因。社会的发展以及人权保障的理念深入人心,并成为刑法的首要机能^①,这使得刑罚设置偏重的现行刑法饱受“厉(严厉)有余而严(严密)不足”的诟病。罪刑设置的失当以及新的侵害行为不断出现,使得立法者在进行刑法修正时重点考虑“严”而非“厉”,这也直接导致了刑法修正以犯罪化的刑事

* 中南财经政法大学博士后研究人员,中南财经政法大学刑事司法学院讲师,法学博士。本文受司法部国家法治与法学理论研究项目《〈网络犯罪公约〉与我国刑事政策研究》(项目批准号:14SFB20016)、中南财经政法大学高校基本科研业务费项目(项目批准号:31541410702)和中南财经政法大学博士后科研项目资助。另外,感谢中南财经政法大学齐文远教授在本文撰写中给予的悉心指点。

① 参见刘艳红:《刑法目的与犯罪论的实质化》,载《环球法律评论》2008年第1期。

立法为主。犯罪化的刑事立法在刑法修正案中主要表现为两种形式:

1. 创设新罪

例如,《刑法修正案(一)》增设了隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、会计报告罪。《刑法修正案(三)》增设了投放虚假危险物质罪。《刑法修正案(四)》增设了非法雇佣童工劳动罪。《刑法修正案(五)》增设了妨害信用卡管理罪。《刑法修正案(六)》增设了强令违章冒险作业罪。《刑法修正案(七)》增设了利用影响力受贿罪。《刑法修正案(八)》增设了危险驾驶罪。《刑法修正案(九)》增设了组织考试作弊罪,等等。以上笔者仅对各修正案例举了一个罪名,事实上,各个修正案基本上都增设了多个罪名,如《刑法修正案(四)》增设了三个,而《刑法修正案(七)》则增设了九个。上述例证表明,直接创设新罪一直是刑法修正的重要内容。

2. 修改旧罪

与直接增设新罪以扩大打击面的做法稍有不同的是改造旧罪,即通过修改现有犯罪的犯罪构成来扩大犯罪圈。例如,《刑法修正案(二)》就将非法占用耕地罪的“耕地”扩展为包括林地和耕地在内的农用地。《刑法修正案(三)》则将危险物质纳入了危害公共安全的犯罪之中。《刑法修正案(五)》则对信用卡诈骗的客观行为进行了扩张,使得信用卡诈骗罪规制范围进一步扩大。因此,改造旧罪看似没有直接创制新罪,但实质上是刑法原本没有规定的行为纳入了刑法规制,与直接创设新罪的做法可谓殊途同归。

不断增设的新罪加上频繁改造的旧罪,其目的只有一个——不断扩大犯罪圈,这彰显了立法者严密刑事法网的意旨。需要指出的是,刑法的历次修正中也存在着去罪化的规定,如《刑法修正案(七)》对逃税罪的修订,将逃税后补缴税款的行为不认定为犯罪。但这仅是对逃税罪的构成要件进行限缩处理,而非真正减少罪名本身。应当肯定的是,这的确是缩小犯罪圈的有益尝试。不过此种修正不是刑法修正的主流,“犯罪化”才是历次刑法修正的主色。刑法的历次修正表明:现行刑法规定越来越“严”——当然是“严密”而非“严厉”。

(二) 刑罚的轻缓化趋势

波澜壮阔的人权主义运动以及刑法人道主义的滚滚潮流,在刑事立法上的重要反映就是刑罚轻缓化。如果说《刑法修正案(七)》降低绑架罪的法定刑是此种理念的个别表征的话,那么实质性践行该种观念的则是《刑法修正案(八)》对13个死刑罪名的废除和《刑法修正案(九)》对九种犯罪的去死刑化。死刑被认为是刑法不人道的重要体现,而我国是死刑罪名规定多、判决多和执行多的“三多”国家,这与世界各国主张废除死刑或限制适用死刑的潮流背道而驰。《刑法修正案(八)》一举废除了13个死刑罪名,《刑法修正案(九)》在此基础上又取消了9个死刑罪名,为我国死刑的废除推开了一扇重要且影响深远的窗。死刑罪名的不断减少直至废除可以说是刑法轻缓化的最好体现。细观这两次有关死刑废除的修订,一个可喜的变化是,死刑的废除由暴力犯罪罪名扩展至经济型非暴力犯罪罪名:《刑法修正案(八)》仅涉及暴力犯罪的死刑废除,而

《刑法修正案(九)》则开始着手废除经济型非暴力犯罪的死刑,如集资诈骗罪。因此,死刑在更大的范围和程度上进一步废除是我国将来更长时间内的刑事立法重点,这也是我国刑罚体系进一步轻缓化的重要体现^②。

从笔者梳理的有关刑法修正的两个基本特征可以看出,我国刑法的修正一方面不断犯罪化,以扩大打击面;另一方面又不断轻缓化,不断减少死刑罪名和降低个罪的法定刑,二者交织进行,并行不悖。由此可知,迄今为止的历次刑法修正,正使得我国刑法总体上从“厉而不严”走向“严而不厉”。可以预见,这也将是未来一段时间内我国刑法修正的基本思路。有人认为,“犯罪化”也意味着刑法的“严苛化”——将更多的行为认定为犯罪本身就是刑法严厉的体现。^③应当承认,由于刑法是最为严厉的“保障法”,将原本非犯罪的行为纳入刑法规制,对于该类行为而言的确是“严苛化”的体现。但也应当指出的是,扩大刑事法网与其说是“厉”,不如说是“严”,因为“厉”主要表现为刑罚的轻重,而“严”则主要表现为罪名的多少。因此,笔者并不赞同以罪名的增加来否定我国刑罚轻缓化的趋势。事实上,罪名的多少并不会直接影响刑罚轻缓化的评价。我国之所以被称之为刑罚最为严厉的国家之一,主要原因并非是由于罪名设置过多,而是在于刑罚设置过重。较为直观的例子是,尽管《刑法修正案(八)》废除了13个死刑罪名,《刑法修正案(九)》取消了九种犯罪的死刑,但我国仍然是死刑罪名设置最多的国家之一。与此相反,尽管域外许多国家刑法罪名、条文数量远远超过我国刑法,也并未被冠以“刑罚严厉”之名,这也从一个侧面反映了罪名与条文的多少与刑罚严厉与否关联性不大。

一般认为,在崇尚人权保障的当代社会,刑罚设置严厉与否是衡量刑法好坏的重要标准。有学者认为,“好的刑法,应该是‘严而不厉’。不过他同时也指出,增加犯罪类型在整体思路上没有问题,但应当更加慎重。”^④也就是说,刑法可以通过增设条文(新罪)来扩大保护范围,但刑罚则不能过于残酷。笔者也认同“好的刑法”应当“严而不厉”。一方面,以“恶法”形象示人的刑法应当将刑罚设置进一步轻缓化,因为现代法治国家无不强调人权保障的基本理念,所以好的刑法应当“不厉”;另一方面,好的刑法也应当将构成犯罪的行为均纳入刑法规制,实现刑法的天然属性,即社会保障机能,这就要求刑法“很严”,做到不枉不纵。做到“不厉”较为容易,这可以直接通过削减死刑罪名、降低个罪的法定刑得以实现。而“很严”却难以达到,直接增设罪名的做法固然可以使得刑法的覆盖面扩大,给人感觉刑法更加“严密”。然而,好的刑法所追求的“严”显然不是罪名越多越好,“不厉”所隐含的实质意义在于刑罚的人道性,而“严”的实质含义在于“不漏”,即做到“需要惩处的均予以惩处”。从短期来看,直接增设罪名以使刑法更为“严密”的做法尽管简单有效,但从长远来看,却难以真正实现“不漏”。在“不厉”的目

② 参见高铭暄、苏惠渔、于志刚:《从此踏上废止死刑的征途——〈刑法修正案(八)草案〉死刑问题三人谈》,载《法学》2010年第9期。

③ 参见仝作俊、刘蓓蕾:《犯罪化与非犯罪化论纲》,载《中国刑事法杂志》2005年第5期。

④ 任重远:《刑法第九次修订启动:死刑罪名少了,犯罪类型多了》,载《南方周末》2014年10月30日。

标逐步实现之后,“不漏”将是我国刑法修正今后所需要着重考虑的问题。

二、刑法修正应追求的目标:从“严而不厉”到“疏而不漏”

法律的权威性在一定程度上取决于法律的稳定性,朝令夕改式的法律难以得到人们内心真正的遵守和认同,刑法亦是如此。“刑法一经制定与颁布,就是一种客观存在,与立法原意产生距离,脱离作者的原意,按照其自足的生命生存下去。”^⑤而社会却处在不断变化和发展之中,静止的法律何以能适应变动不居的社会现实?在提倡造法者的惯性思维中,不断的修改法律以回应社会的发展变化恐怕不可避免。也就是说,刑法为了涵摄日益发展变化的生活事实而不得不动地修改自身以适应现实的需要。因此,刑法修改的直接动因和基本诉求就是意欲规制新的危害行为和犯罪事实。然而,社会生活事实的无限性与法律规定的有限性是包括刑法在内所有法律必须面对且无法克服的矛盾。因此,不论刑法如何扩容(增设新罪),也无法涵盖千变万化、活生生的所有社会事实。那么,以增加刑法条文(罪名)为代表的不断犯罪化能否真正实现严密刑事法网的目标?笔者认为这个问题需要仔细辨析。

(一)刑法条文多寡的影响因素

诚然,我国现行刑法仅有四百多个条文,与动辄上千条文的国家相比,我国刑法条文显得相对较少。刑法条文的创制固然与危害事实和危害行为有关,也与该国的立法传统、经验与习惯,乃至与该国的法制文化密切相关。例如,《日本刑法》第208条设置了暴行罪,暴行罪“是指对他人施加暴行而未致人伤害的犯罪。”^⑥我国刑法并没有规定“暴行罪”,但有学者呼吁在我国刑法之中设置“暴行罪”,以规制“虐童”行为。^⑦而笔者认为,我国刑法没有增设“暴行罪”的必要。“暴行”一词的含义由于语境、文化的不同而不同。日本刑法中的“暴行”具有特定的含义,并非仅指“没有造成轻伤以上的伤害行为”。在日本刑法中,暴行的含义既包括有形的物理力,也包含使用无形的电流、声音、光线等方式干扰他人的行为。^⑧这显然与汉语语境中对“暴行”的理解大相径庭。在汉语体系中,“暴行”一般特指暴力侵害他人身体的行为,不包括使用无形方式骚扰他人的行为。因此,日本刑法中的“暴行”一词与我国的“暴行”用语在含义上存在较大的区别,并不能直接照搬使用。

需要特别指出的是,日本刑法设置“暴行罪”是由其立法技术和习惯所决定的。根据日本刑法的规定,其在总则只是规定了未遂犯的定义,至于是否处罚未遂犯,则是由刑法分则规定的。换言之,只要刑法分则没有犯罪未遂的规定,是不能处罚犯罪未遂

⑤ 张明楷:《司法上的犯罪化与非犯罪化》,载《法学家》2008年第4期。

⑥ 张明楷:《外国刑法纲要》(第二版),清华大学出版社2007年版,第461页。

⑦ 参见孙运梁:《我国刑法中应当设立“暴行罪”——以虐待儿童的刑法规制为中心》,载《法律科学》2013年第3期。

⑧ 参见[日]西田典之:《日本刑法各论(第六版)》,刘明祥、王昭武译,法律出版社2013年版,第40页。

的。例如,《日本刑法》第199条规定了“杀人罪”,与此同时,在203条规定了“杀人未遂罪”,意味着杀人未遂可以成立犯罪。但是,《日本刑法》第204条规定了“伤害罪”,但却没有关于处罚未遂的规定,因此,伤害罪是没有未遂犯的。暴行罪的设置正是作为“伤害未遂”替代形式而出现的,亦即根据日本刑法的规定,伤害未遂行为不构成伤害罪(未遂),而是成立暴行罪。反观我国刑法,《刑法》第23条对故意犯罪的犯罪未遂作出了规定,而并非在分则中明文规定处罚未遂犯。这意味着从理论上而言,我国刑法可以处罚包括故意伤害罪在内的所有犯罪未遂。当然,理论上具有处罚可能性并非意味着在司法实践中对犯罪未遂一概处罚。在故意伤害罪的具体认定上,轻伤害的未遂一般不以犯罪论处,而只处罚重伤害的未遂。^⑨显然,这是采用了与日本刑法完全不同的立法技术。这种差异最为直接的体现是,伤害未遂行为在日本刑法中应当成立暴行罪,而在我国刑法中则成立故意伤害罪(重伤未遂)。通过上述分析可知,与我国刑法相比,日本刑法多设的“暴行罪”也并不意味着日本刑法对人身权益的保护更加严密。

由此可知,刑法条文的多寡是一个受多种因素影响的复杂问题,并非仅以危害行为作为唯一考量因素。因此,刑法条文的多与少并非直接与犯罪行为的数量和种类相关,而是基于多种因素综合影响的结果。

(二) 刑法条文多寡与刑事法网的严密

相对而言,条文设置较多的刑法的确比设置较少的刑法保护范围更大、打击面更广,似乎可以得出条文多的刑法比条文少的刑法更显得严密的结论。然而,有限的刑法条文不可能涵摄无限的生活事实。从这一点而言,再多的刑法条文面对无穷变化的生活事实也是捉襟见肘。社会总是在不断的发展变化,危害行为也总是不断的推陈出新,若刑法也随之常变常新的话,刑法恐怕最终将成为一部“史书”。从理论上来说,用刑法试图规制无限的生活事实终究是“不可能完成的任务。”因此,刑法条文越多,只是相对而言,而并非是真正意义上的刑事法网严密。因为与无限变化的生活事实相比,刑法永远是“疏”而不可能是严“密”的!

综合上述两点,笔者认为,刑法修正的目标,应是尽可能地做到“疏而不漏”。在人权与人道不断被强化的今天,刑法不能过于严酷,这已经成为共识,并成为好的刑法的重要判断标准。要做到“严”,刑法修正追求的效果和状态应是“疏”而不“漏”。立法者应当思考的是,如何通过有限的刑法条文去规制不断变化的生活事实。古语云“天网恢恢,疏而不漏”,反映的正是通过“疏”之法律实现“不漏”之法律效果。问题是,如何切实有效地实现“疏而不漏”?一味的增加刑法条文显然无法实现真正的“严”,因为相对于无法穷尽的危害行为来说,刑法条文再多也只能是“疏”。因此,既然通过增加刑法条文实现刑法“严”的追求难以实现,不如转换思路,承认刑法“疏”的现实,以实现刑法“严”的诉求!好的刑法能够以有限的刑法条文规制千变万化的危害行为,以达到最大限度保护法益之目的。

^⑨ 参见张明楷:《刑法学》(第四版),法律出版社2011年版,第766页。

总而言之,纵观我国历次刑法修正,其最为重要的追求是严密刑事法网,实现“疏而不漏”。至于如何实现“疏而不漏”,持不同立场和观点者的回答并不一样。

三、严密刑事法网的进路选择:释法优于造法

众所周知,法律一经创制,必将滞后于生活,刑法亦不例外。当社会生活中出现某种新类型的行为需要纳入到刑法规制时,可以采取两种不同的方式:解释刑法或者创设新法,前者可以称之为释法论,后者可以称之为造法论。释法论认为,当刑法出现所谓的疏漏时,首先应当考虑解释刑法。刑法学的任务并不是‘设定’刑法漏洞,相反,应当合理填补漏洞。与此相对应,造法论则认为,当刑法出现漏洞时,首先应当考虑修法,以创设新法来弥补漏洞。例如,在《刑法修正案(九)》颁布之前,是否为“单纯的收受礼金的行为”增设“收受礼金罪”曾引发热议。当利用职务之便收受礼金但没有为他人谋取利益时,释法论者首先考虑的是,该种行为能否通过解释刑法来进行规制?进而通过对受贿罪构成要件进行合理解释,从而得出该种行为可以成立受贿罪的结论。而造法论者则认为,刑法没有规定单纯的收受礼金但并不为他人谋利的行为,而该种行为又必须作为犯罪惩处,因此,应当增设“收受礼金罪”,以对其进行规制。虽然“收受礼金罪”由于多种原因最终没有能写入《刑法修正案(九)》,但释法论与造法论的分歧由此可见一斑。针对上述两种不同完善刑事法网的进路,笔者认为两者并不矛盾,可以并存。不过,释法论在位阶上应当优于造法论,即刑法出现“疏漏”时,首先应当考虑解释刑法,只有当运用刑法解释理论已经不能填补疏漏时,才能考虑创设新法。因此,释法并不排斥造法,只有当释法不能弥补疏漏且必须规制既有行为以保护某种法益时,才能选择造法。释法之所以优先于造法,理由如下:

(一)造法与释法对严密法网的功用

如前所述,法律的有限性与社会生活事实的无限性是无法克服的矛盾,是故,创设新法只能起解决“近忧”之用,而无法担当“远虑”之责。从长远来看,危害行为总是不断地变化,且层出不穷,而刑法条文却不可能无限扩张。立法者和司法者必须面对的问题是,如何用有限的刑法条文去规制无限的危害行为?从根本上来说,这显然不是造法可以解决的问题。因此,试图以造法的方式将层出不穷的危害行为纳入刑法规制无异于饮鸩止渴,终究不是长远之计。既然刑法之“疏”在所难免,能使“疏”之刑法实现“不漏”效果的只能是释法。“谁又可能预见全部的构成事实,它们藏身于无尽多变的生活海洋中,何曾有一次被全部冲上沙滩?”^⑩面对千变万化的生活事实,法律从创制出的那一天起,就注定了滞后、无法涵摄所有生活事实的命运。因此,从现有的法律规定之中去探寻和阐释其丰富内涵,使之与时代和生活事实更好的对应,成为法律学者天然的使命。法律的滞后性与有限性决定了法律解释存在的必要性与重要性。只有解释刑法

^⑩ [德]拉德布鲁赫:《法学导论》,米健译,中国大百科全书出版社1997年版,第106页。

(释法)才能使“疏”之刑法实现“严”之诉求,真正做到“疏而不漏”。

刑事立法者创制了刑法规范,而刑事司法者必须将既有的刑法规范与客观案件事实结合起来,从而形成刑事判决。刑事司法的过程,实际上是将刑法规范与案件事实进行反复比照、判断是否吻合的过程。一方面,司法者需要对刑法规范进行解释使之具体化,以使其能够与案件事实相对应;另一方面,司法者也需要将具体的案件事实归纳、抽象,以寻找对应的刑法规范。前者是将刑法条文由抽象演绎为具体,而后者则是将案件事实由具体归纳为抽象,在这两个过程之中,对法律的解释必不可少,并起着举足轻重的作用。事实上,“解释者对法律的理解可能比创立者对法律的理解更好,法律也可能比起草者更聪明——它甚至必须比它的起草者更聪明”,^①要使凝固的法律文本适应多变的社会现实,法律适用者就必须更好地理解法律。法律文本虽一经制定就已经固化,但其又必须是开放的,即便立法者当初没有能够想到的事实,经过精巧的解释仍然可以涵摄到刑法规范之中。只有这样,“恢恢之网”,才能“疏而不漏”。“法律解释乃法律适用上最重要、最困难的工作。”^②总而言之,法律为满足永久变动的社会需要,其不能、也不允许频繁地修改、增设法律以使得法网更加严密,这就为包括刑法解释在内的法律解释提供了存在的理由和生存的空间。

(二)释法优于造法与法的稳定性的维护

博登海默认为,“一个完全不具有稳定性的法律制度,只能是一系列为了对付一时事变而制定的特定措施。它会缺乏一致性与连续性。这样,人们在为将来安排交易或制定计划的时候,就会无从确定昨天的法律是否会成为明天的法律。”^③法的稳定性是法律的根本属性之一,朝令夕改的法律自然无法得到民众的认同和遵守。“法律不应太轻易得以改变,一个临时性的立法便无法保证同样可靠地执行。”^④造法一般体现为两种形式,即创设新法和修改旧法。无论是哪种形式,都意味着对既有法律进行修改。笔者并非反对对既有法律进行任何形式的修改,但频繁的修改显然影响法的稳定性。因此,与其说笔者反对造法,不如说反对的是未经合理释法就草率的造法的做法。例如,《刑法修正案(八)》第49条增设了“食品监管渎职罪”,指出“负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员,滥用职权或者玩忽职守,导致发生重大食品事故或者造成其他严重后果的”,构成本罪。其实,该罪的行为完全可以由《刑法》第397条所涵括,直接认定为滥用职权罪或者玩忽职守罪。《刑法修正案(八)》之所以设置“食品监管渎职罪”,无非是由于食品安全问题频发,需要监管部门加大、加强监管力度,进而以增设罪名的方式强化监管部门的职责。殊不知,本罪的增设,实质上是对《刑法》第397条所规定的“滥用职权罪、玩忽职守罪”的狭隘理解,是完全没有必要的草率造法。

当然,释法的边界是罪刑法定原则,当法律解释超越了法律文本本身含义之射程

① [德]拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴译,法律出版社2005年版,第115页。

② 王泽鉴:《民法概要》,中国政法大学出版社2003年版,第19页。

③ [美]博登海默:《法理学——法哲学及其方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第339页。

④ [德]考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2004年版,第276页。

时,通过刑法解释无法规制现有的生活事实,此时解释论必须让位于造法论,否则就是违反罪刑法定的类推解释。“苟律无明文,即不得深文罗织,以无为有、以轻为重,不然,类推论断,好恶随心,欲加之罪何患无辞,故类推非刑法所许。”^⑮以对“交通肇事后逃逸”的解释为例,有学者认为,交通肇事后行为人虽未逃离现场,但拒不救助被害人,也可以认定为“交通肇事后逃逸”。原因在于,刑法之所以将“交通肇事后逃逸”的行为加重处罚是因为行为人在能够救助被害人的情形之下却不救助,故而升格法定刑加重处罚这种拒不救助的不作为犯。同理,在交通肇事发生之后,行为人虽未逃离现场,但也不救助,这本质上也属于拒不救助的不作为,因而可以适用“肇事后逃逸”的刑法规定。^⑯笔者认同“逃逸”行为的本质在于行为人不救助被害人即不作为,并且认为刑法之所以将“逃逸”行为升格法定刑,目的在于促使行为人救助被害人以保护被害人的利益。但是,笔者并不认同将“不逃跑但也不救助”的行为认定为“交通肇事后逃逸”。原因很简单,虽然站在现场拒不救助的行为是不作为的伤害行为,但无论如何也不能将“站立现场不逃跑”的行为解释成“逃逸”,这与一般人对“逃逸”的理解相去甚远,超越“逃逸”一词字面含义的射程,也超越了国民的预测可能性。在一般人看来,“逃逸”特别是“肇事后逃逸”必须存在空间上的位移,也就是说,逃逸必须是脱离事故现场的行为,若将行为人“留在现场不救助”的行为也解释成“逃逸”,这是典型的逾越“逃逸”字面含义的类推解释,违反了罪刑法定原则。因此,若需要对行为人“留在现场但不救助”的行为作升格法定刑处理,已不再是刑法解释可以完成的任务,必须另行创设新法才能解决。此时,释法功能已然穷尽,必须借助造法来实现处罚的目标了。

由此可知,释法并不绝对排斥造法,但从维护法的稳定性而言,释法更具优势。维护法律的稳定就是维护法律权威,这是“法治”的应有之义。

(三) 释法优于造法有助于发现法律的真实含义

西谚有云:法律不是嘲笑的对象。集众人之智的法律远不像许多人想象的那么简单,更不是漏洞满身的“百家衣”,我们许多时候发现的所谓法律漏洞,只不过是对于我们没有更好、恰当地理解我们的法律罢了。法律创制后虽然已经文本化,但法律条文的真实含义并未随之固化,法律适用者完全可以与时俱进地在不违反罪刑法定原则的前提下不断地去发现法律的真实意义。“法的理念作为真正的正义的最终的和永恒的形态,人在这个世界上既未彻底认识也未彻底实现。”^⑰例如,《刑法修正案(五)》针对《刑法》第196条信用卡诈骗罪,在第一款第一项中增加了“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的”规定,使得原规定变为“使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的”。《刑法修正案(五)》之所以增加这一条规定,是因为“伪造的信用卡”无法涵摄“以虚假的身份证明骗领的信用卡”,因为用虚假的身份证明骗领的信用卡,该卡

⑮ 韩忠谟:《刑法原理》,中国政法大学出版社2002年版,第48页。

⑯ 参见姚诗:《交通肇事“逃逸”的规范目的与内涵》,载《中国法学》2010年第3期。

⑰ [德]科殷:《法哲学》,林远荣译,华夏出版社2002年版,第10页。

片是真实并且可用的,只是卡片所有人身份与持卡人不相符合罢了。这也是立法者增设该条的原因所在。笔者以为,该条的增设值得商榷。“以虚假的身份证明骗领的信用卡”无外乎两种情况:一是身份证明客观上并不存在,行为人使用(伪造)虚假的身份证明骗领信用卡;二是身份证明客观上存在(即存在真实的该身份),行为人冒用该人的身份证明骗领了信用卡。两者的差异是,前者是伪造了一个客观上不存在的对象进行骗领,即冒用的对象不存在;而后者则是用他人的真实身份证明进行骗领,冒用的对象真实存在。两者的共同点是,骗领的信用卡是真实有效的,且不是“自己”的,而是“他人”的。由此可知,行为人“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡”的行为,本质上就是“使用他人信用卡”的行为,符合“冒用他人信用卡”的规定。尽管“冒用他人信用卡”原本是指行为人使用“他人”(而不是行为人)经合法程序申领的真实有效的信用卡,这与“使用以冒用他人身份骗领的信用卡”存在着细微差异,但两种行为本质上均属于行为人使用他人真实可用的信用卡的行为,利用刑法解释将“使用以冒用他人身份骗领的信用卡”的行为纳入“冒用他人信用卡”的行为范畴并不存在太大的问题,也没有超越国民的预测可能性。是故,笔者认为,《刑法修正案(五)》增设的“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的”规定,是对“冒用他人信用卡”的条文即有不正确理解造成的,属于完全没有必要的造法。

由此可以看出,有些修正案的草率造法是没有对现有法律规定进行透彻理解的结果,是对已有法律条文的僵化思考,是不可取的。树立释法优于造法的法律思维,尊重并认真地对待即有法律文本,有助于深入、理性地把握法律的真实含义。

(四)造法的优势并不强于释法

尽管从创制机关而言,造法效力高于释法效力。但在具体的司法实践中,司法解释却具有强大的具体适用力。^⑩任何法律条文都需要解释才能具体地运用到案件当中去,司法解释天然的履行着这种使命。近年来,司法解释颁布的数量越来越多,颁布的速度也越来越快。通过简单梳理可知,每一部刑法修正案背后都对应着多个司法解释。事实上,司法机关对司法解释的遵守和运用甚至超过了刑法文本。也许此种状况值得反思。但从适用性角度而言,造法产生的刑法修正案并不比释法生成的司法解释更具优势。另一方面,至少从立法解释的视角而言,造法在解释原则、解释对象、解释方法、解释内容乃至解释结论上均无法与释法进行真正的区分。“立法解释与司法解释的共同点在于:两者行使的均是对现有法律条文的解释功能,并未改变条文的数量和内容,而是对刑法条文中用语的具体概念进行阐释。”^⑪“立法解释”一词兼含“立法”与“解释”两个意义,是以立法的形式对法律进行解释。因此,立法解释是立法机关通过立法的形式对法律进行的解释,从效力上而言,属于法律;从内容上而言,属于法律解释。立法解释也有可能违背罪刑法定原则。“因为人们呼吁立法解释时,常常是由于自己不能作出

^⑩ 参见张明楷:《简评近年来的刑事司法解释》,载《清华法学》2014年第1期。

^⑪ 李翔:《刑法修订、立法解释与司法解释界定之厘定》,载《上海大学学报》(社会科学版)2014年第3期。

某种解释,觉得自己的解释超出了刑法用语可能具有的范围因而属于类推解释,违反了罪刑法定原则,才要求立法机关作出解释。”^⑨立法解释虽然通过立法的方式将类推解释“合法化”,但这种解释本质上仍超越了国民预测可能性而违反罪刑法定原则。因此,以立法解释形式存在的造法不但可能违反罪刑法定原则,而且无法与司法解释进行真正有效的区分,因而并不具备优势。

(五) 释法相较于造法而言更具经济性

目前我国刑法的造法形式主要有两种:即刑法修正案和刑法立法解释。无论是修正案还是立法解释,从性质上来说均属于“法律”。根据我国《宪法》第67条的相关规定,“对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改”以及“解释法律”均由全国人民代表大会常务委员会作出。以刑法修正案为例,根据我国《立法法》的规定,从动议修改刑法到最终刑法修正案的颁布施行,在法律程序上应经过提出法律草案、审议法律草案、表决法律草案、颁布施行四个阶段。在此过程之中,列入全国人大常委会会议议程的法律案,一般应经三次常务委员会会议审议后再交付表决。并且,“法律案有关问题专业性较强,需要进行可行性评价的,应当召开论证会,听取有关专家、部门和全国人民代表大会代表等方面的意见。”由此可见,一部刑法修正案从草案到最终颁布施行经过了极其严格的立法程序,这种程序需要投入巨大的人力、物力和财力。从这个意义上来说,刑法修正案的创制是成本极高的“造法”。与此相对,作为“释法”的司法解释,由最高人民法院和最高人民检察院作出,相较于“造法”极为复杂的立法程序,司法解释的创制程序较为简单。根据《最高人民法院关于司法解释工作的规定》,司法解释的创制过程需要经过立项、起草和报送、讨论、发布施行等四个阶段。与“造法”需要内外多方不同力量共同参与不同,作为“释法”的司法解释在最高人民法院即可以完成全部过程。“提出、草拟司法解释内容的单位,可以是最高法院内设的某一或某几个审判业务庭,如刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行办公室、赔偿办公室、研究室等”,经过最高法院审判委员会全体会议讨论通过,则成为“司法具有普遍约束力的法院规范解释。”^⑩因此,作为“释法”的司法解释在提出主体、审议过程、草案表决生效等程序方面具有简约性,与“造法”相比成本较低。正因为如此,释法比造法更具有经济性。根据成本—效益的一般原理,在产出基本相等的情况下,选择较低的成本支出显然更具效益。

综上所述,针对严密刑事法网的两种不同进路即释法或与造法,笔者认为释法在位阶上应当优先于造法,只有穷尽释法的功能仍无法弥补漏洞时才能考虑造法。申言之,只有在释法无法解决法律所存在的疏漏且又必须对之进行规制时才能造法。轻率的造法是一种简单化解决问题的思路,这与“法治”和“法制社会”的理念并不相符。

^⑨ 张明楷:《立法解释的疑问》,载《清华法学》2007年第1期。

^⑩ 参见陈春龙:《中国司法解释的地位与功能》,载《中国法学》2003年第1期。

四、对刑法功能泛化的省思：犯罪化的刑事立法应当限制

自现行刑法颁布以来,随后共颁布了九个刑法修正案,新增罪名40余个,可以说犯罪化是晚近以来我国刑事立法的绝对主导。“刑法立法已成为我国立法活动中最积极、最活跃的一个方面。这种积极不仅表现为立法活动的频繁,还表现在立法内容上的取向,在历次对刑法的修改中,基本上是增加罪名或者加重对某些罪名的刑罚。”^②在这种思维的影响下,每次全国人民代表大会的召开,总会有一些代表建议增设新的罪名,诸如增设“通奸罪”、“吸毒罪”、“卖淫嫖娼罪”、“奴役罪”等立法建议,吸引了众多媒体和民众的目光而获得了极高的关注度。普通大众对刑法的高度关注并因此产生的“新罪情结”在刑法的历次修正中得到了体现,如拒不支付劳动报酬罪、危险驾驶罪等罪的创设鲜明地体现了这种思维和趋势。纵观迄今为止的历次刑法修正,罪名的增设至少存在两个问题:

(一) 罪名设置动因存疑

为何增设新罪,增设何种新罪本是一个极为复杂的问题,然而,近些年来的刑法修正关于新罪的创设侧重考虑的是“民生”和“民声”。诚然,刑法应当回应和关注社会现实,也应当考量民生和关注民意,但刑事立法不仅仅是颁布给民众“看”的,它有着自身的逻辑和必须恪守的准则。刑事司法解释如此,刑事立法何尝不是!组织残疾人、儿童乞讨罪,拒不支付劳动报酬罪,危险驾驶罪等就是立法满足“民意”的生动体现。以此标准来增设新罪,至少存在几个方面的问题:

1. “民众呼声”不一定真正代表并体现“民意”

“民意”内容含混庞杂,且其产生及传播受到多重因素的影响,尤其受到传播渠道即媒体的支配性影响,这使得什么是真正的民意难以判断和明确。少数人的歪曲捏造、媒体的不当宣传都可能影响民意,甚至使得具有某种个人偏好的观点、意见成为所谓的“民意”。“民意”的不确定性以及难以判别性使得“民意”不能成为刑事立法的主要动因和标准。

2. 刑法对民生的保障应恪守刑法的谦抑性和保障性原则

有学者认为,《刑法修正案(八)》因为较多地关注“民生”问题,从而使现行刑法有了“民生刑法”的特色。^③笔者认为,刑法关注和保护民生并没有问题,但若过分介入民生则成为问题。也就是说,刑法对民生的保障必须恪守刑法的谦抑性和保障法原则,倘若刑法过分介入民生并成为民生保障的常规手段,只会适得其反。“刑法是一门具有高

^② 郎胜:《在构建和谐社会的语境下谈我国刑法立法的积极与谨慎》,载《法学家》2007年第5期。

^③ 参见卢建平:《加强对民生的刑法保护》,载《法学杂志》2010年第12期;张勇:《民生刑法的品格:兼评〈刑法修正案(八)〉》,载《河北法学》2011年第6期。关于民生刑法的概念、价值以及在我国展开论证,参见车明珠:《民生刑法初论》,载《刑法论丛》2012年第4卷。

度专业和技术的学科,具有自身的特殊性,刑法如何关注和解决民生问题必须充分考虑刑法的属性。”^{②4}将刑法视为社会管理常规手段的做法无疑是对刑法功能的滥用。作为最严厉部门法的刑法是其他部门法的保障法,因此,对于社会治理中的绝大多数问题不应也不能由刑法进行解决。以刑法介入保护来彰显某类问题、某个领域重要的做法归根结底是“严刑峻法”的思维在作祟,是“用牛刀杀鸡”式的不当做法。刑法过度介入反映的是国家对刑法价值的理解偏离,这将导致社会治理面临巨大的风险,这种风险主要在于,以刑法作为社会治理的常规手段将改变社会治理各个手段之间的体系平衡,致使各个治理方式、手段之间秩序紊乱、轻重失当。社会治理过度刑法化本质上是“刑法依赖综合症”的体现——“任何层面力有不逮时,设立新罪、刑法登场总会成为最终的选择。”^{②5}这不但使得其他社会治理手段功能难以有效发挥,也使得刑法自身陷入了毫无节制使用导致功能不断削弱的泥沼。近年来,刑法的多次修正,使得刑法对诸多领域进行介入保护,为了强调刑法保护的重要性,根据介入、保护的领域不同而创造性地使用了“特色刑法”的称谓。“医疗刑法”、“环境刑法”、“劳动刑法”等一时成为刑法学研究的热门领域和时髦词汇。笔者并不反对上述提法,只是谨慎的认为,若刑法对某个领域进行保护,就获得“某某刑法”的称谓以彰显刑法特色的话,恐怕刑法最终将成为“特色刑法(领域特色)”而丧失“刑法特色(自身特色)”。因此,笔者不赞成刑法过分介入、强调保护某一领域,刑法对犯罪的规制和法益的保护应当依据自身的逻辑和具体现实情况而定。刑法对某一领域的保护也并不意味其具有该领域特色而成为“某某刑法”,因为刑法的保护几乎涵盖了社会生活的各个领域,而非专注于某一领域。刑法是保护最低限度的利益平衡,其重点不在固定利益项目的(所谓法益)质的保护,也不在固定利益项目的量的保护^{②6}。

3. 罪名设立应具有实用性

基于“民生”或“民意”设置的罪名可能导致实用性不够而“不接地气”。“民意”所反映和关注的热点问题通常具有即时性和短暂性的特点,缺乏长远性和宏观性,缺乏对“热”点问题的“冷”思考。这种“热点”式立法思维容易导致创设的罪名实用性不足。比如,《刑法修正案(六)》创设的组织残疾人、儿童乞讨罪就是一个极少适用的“沉睡”条款。本罪是为了与《治安管理处罚法》进行有效衔接的产物。^{②7}据笔者考查,直到2012年8月13日,上海市才批捕首例组织残疾人乞讨罪。^{②8}也就是说,自《刑法修正案(六)》颁布六年之后,才认定了第一起组织残疾人乞讨罪。当然,设置罪名并不意味着罪名适用越多越好,但“热点”罪名较少适用或者基本不用,不能不使人对该罪名设置的

②4 何荣功:《要慎重对待“民生刑法观”》,载《中国检察官》2014年第2期。

②5 刘艳红:《当下中国刑事立法如何谦抑?——以恶意欠薪行为入罪为例之批判性分析》,载《环球法律评论》2012年第2期。

②6 参见黄荣坚:《基础刑法学》(上),中国人民大学出版社2009年版,第27页。

②7 参见关于《刑法修正案(六)》草案的说明。

②8 参见蔡顺国:《上海批捕首起组织残疾人乞讨嫌犯》,载《检察日报》2012年8月15日。

原因和功用生疑,这也是一种不讲效益的造法。

(二) 罪名设置的前瞻性问题

正如有学者所指出的那样,“前七次刑法修正案就在不同程度上体现了我国刑事立法者的短视,诸如《修二》、《修五》等,都是急功近利立法观的产物。”^②刑法修正案罪名设置的前瞻性不够主要表现为对同一罪名的反复修改。比较典型的是洗钱罪的构成要件修改过程。在1997年刑法中,洗钱罪的上游犯罪原本只有“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益”三种类型,此后《刑法修正案(三)》将“恐怖犯罪所得及其产生的收益”纳入其上游犯罪之中,而《刑法修正案(六)》则进一步将洗钱的对象扩大到“贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益。”从《刑法修正案(三)》到《刑法修正案(六)》,刑法修正直观地呈现了洗钱罪构成要件的不断膨胀过程:构成要件内容越来越多,打击面也越来越大。洗钱罪的上游犯罪通过多次修正、反复扩容说明,立法者对洗钱罪的上游犯罪设置的前瞻性存在欠缺,较多的考虑了此时此刻的情形,以问题式思考为主,缺乏对彼时彼刻、长远性的前瞻和规划。此外,对危险驾驶罪的修改也是一个例证。对《刑法修正案(八)》设立的危险驾驶罪,《刑法修正案(九)》就扩大了其客观行为的规制范围,将“在道路上从事客运业务,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的”和“违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品的”纳入危险驾驶罪的范畴。危险驾驶罪在短短三年间就进行修正,不得不让人质疑修法的前瞻性和科学性。更有甚者,“毒驾”入刑言犹在耳,“盲驾”入刑动议已成。^③若依此种逻辑来修正刑法的话,可以预见,危险驾驶罪将在未来几年不断膨胀,会将更多的“危险”驾驶行为纳入规制。假若如此,危险驾驶罪恐将成为一个“危险的犯罪”。^④这种“头痛医头”式的立法模式只考虑解决当前问题,而不考虑法条设置的预见性和前瞻性,实不可取。

尽管新设罪名存在诸多问题,但罪名增设一直在争议中前行,这在历次刑法修正中已经得到证明。在提倡造法以严密刑法者的眼中,刑法犹如一把万能钥匙,“能打开所有的锁”。将刑法视为“万能钥匙”、将刑法当作社会常规管理手段的做法本质上是刑法功能泛化的体现——即意图使用刑法规制和解决所有问题。然而,正如不存在无所不能的灵丹妙药一样,刑法并不是能解决所有问题的“万能之法”,即便面对不断产生的新的违法行为以及已经来临的风险社会,刑法也应当有所为与有所不为,^⑤总体上保持一种克制的态度。犯罪化的刑事立法是工具理性刑法观的体现,是扩大犯罪圈和刑法规制范围的做法,它扩张了国家权力,并限缩了国民权利,与扩张“民权”、限制“政权(政府权力)”的潮流背道而驰。正因为如此,“当今我国的刑事立法应该放弃被扩大的

② 刘艳红:《〈刑法修正案(八)〉的三大特点——与前七部刑法修正案相比较》,载《法学论坛》2011年第3期。

③ 参见孙乾:《委员建议将驾车时玩手机入刑》,载《京华时报》2014年11月1日。

④ 参见杨柳:《危险驾驶罪:一个“危险”的犯罪》,载《江西警察学院学报》2011年第6期。

⑤ 齐文远:《刑法应对风险社会之有所为与有所不为》,载《法商研究》2011年第4期。

刑法万能之理念;面对层出不穷的违法行为,立法者应该‘冷眼观之’而不是动辄入刑。”^③让刑法回归原本的功能和地位,限制刑法功能的过分扩张和泛化,恪守刑法的有限性和谦抑性,强调刑法的保障法地位,这是犯罪化思潮涌动的大趋势下必须重视的问题。如同西谚“让上帝的归上帝,让凯撒的归凯撒”所表达的那样,恪守而非一味地扩张刑法的边界,让刑法的归刑法,在提倡法治国以保障人权的今天尤为重要。

总之,与其千方百计地创设新法,不如深思熟虑地解释旧法;与其强化国家权力创设新罪,不如扩大国民权利限制入罪。作为最严厉的部门法,刑法更应恪守谦抑性原则,将刑法视为无事不办的“管家”做法并不符合“大国法治”的要求。一言以蔽之,对刑法功能泛化的思维应当警惕,对犯罪化的刑事立法应当限制!

五、由“立法中心主义”迈向“释法中心主义”

“造法论”与“释法论”分别体现了“立法中心主义”与“释法中心主义”。立法中心主义以“创造新法”作为基本立场和主要任务;释法中心主义则以“解释旧法”作为基本立场和主要任务。在前述中,笔者以刑法修正作为切入点,分析了造法与释法之间的优劣势,指出提倡释法并不排除造法,作为严密刑事法网的不同进路,释法在位阶上应当优先于造法使用。但这仅仅是在刑法范围之内,并以刑法修正案作为论据所得出的结论而已。从更宏观的层面来看,刑法只是部门法之一,是社会主义法律体系中的一个组成部分而已,针对刑法所作的释法与造法的分析是否经得起在更为宏观层面的检验和推敲,这是不能回避的问题。换言之,关于释法优于造法的论证是否可以作为一个一般性结论应用于整个社会主义法律体系?

关于社会主义法律体系的基本状况,或许从法律性质的归属与划分可见一斑。“从规范性文件的归属角度,截至2010年,中国已经制定宪法和现行有效法律237件,按照全国人大常委会法工委的分类,包括七个法律部门,即宪法及其相关法、行政法、刑法、民商法、经济法、社会法和程序法。此外,现行有效行政法规690多件,地方性法规8600多件。”^④从我国法律规范的数量以及“社会主义法律体系已经形成”可知,我国近三十年来以“建立社会主义法律体系”为目标的造法任务已经基本完成。可以说,我国立法经历了长时间的高歌猛进之后,进入到相对成熟、缓慢的时期。在造法的任务基本完成之后,从现在起至将来较长的一段时期之内,“造法”将不再是法律生活中的主角,“立法中心主义”将转向于“释法中心主义”,这是由以下因素决定的。

(一) 法制状况的基本国情决定

“认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本的根据。”^⑤同样,认清中国法制

^③ 刘艳红:《我国应该停止犯罪化的刑事立法》,载《法学》2011年第11期。

^④ 朱景文:《中国特色社会主义法律体系:结构、特色与趋势》,载《中国社会科学》2011年第3期。

^⑤ 《毛泽东选集》(第2卷),人民出版社1991年版,第633页。

状况的基本国情,也是认清法制问题的基本根据。新中国成立时,我国的法制状况同样是一穷二白,法律制度本来就不多,更遑论形成法律体系。直至1978年十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针之后,我国法制建设进入了快车道。中共十五大以及十六大均明确提出,到2010年要建成中国特色社会主义法律体系。因此,上世纪80年代到2010年的这三十年,是社会主义法律体系的建设时期,也是我国立法最为活跃的时期,这一段时期是典型的“立法中心主义”。社会主义法律体系的建成表明我国法律体系基本完善,法律门类基本齐全。当法律门类基本完善之时,“造法”自然不再是中心任务了,“立法中心主义”失去了存在的现实基础。

(二) 社会主义法律体系的内在要求决定

社会主义法律体系的建成不仅仅表现为形式上法律门类的齐备,更体现为各法律之间的体系协调,共同完成对社会生活领域的规制。从这个角度上来说,法律体系的内在实质协调比法律制度的外在形式齐备更为重要。“在现代国家中,法不仅适应于总的经济状况,不仅必须是它的表现,而且还必须是不因为内在矛盾而自相抵触的一种内部和谐一致的表现。”^⑨实现法律体系的内在协调主要有两个途径:其一,在创制法律的时候,注意法律之间的衔接,实现内在协调;其二,在法律实施过程中,精巧的解释法律,实现内在协调。前者可以称之为“造法”实现协调,后者则是“释法”实现协调。当然,在法律的适用过程中,对不协调之处进行修正也是实现法律之间协调的重要途径。不过,由于对法律修正本身就是“造法”,故可以将其归入“造法”实现协调这一类别。由于社会主义法律体系已经基本建成,通过大规模的“造法”填补法律之间空白从而实现法律之间协调的做法已经不适合现实需要。既然法律体系已然形成,现在亟需解决的问题是,如何理顺各个法律之间的关系,以实现他们之间的内在良性衔接。这显然是“造法”难以解决的问题,“释法”则成为不二之选。例如,是否可以将虚拟的“网络空间”与现实的“公共场所”等同,是认定网络相关犯罪的核心问题之一。“虚拟空间”与现实“公共场所”的关系,不仅涉及到网络犯罪的认定,更涉及到刑法与刑事诉讼法之间的衔接。根据刑事诉讼的犯罪地管辖原则,作为网络犯罪的犯罪地——“网络空间”涉及到侦查、起诉和审判的一系列问题,倘若刑法与刑事诉讼法对“网络空间”与“公共场所”作出不同性质的理解,则会导致刑事实体法与程序法之间的割裂。因此,对于虚拟网络空间性质的认定,既要考虑到刑法上犯罪的认定,也要考虑到刑事诉讼中案件的管辖,即应注意刑事实体法与程序法之间的衔接。对于该问题的解决,只能通过解释法律而不宜创制新法。

(三) 客观案件事实状况决定

“中国法律体系的构建倚重立法、轻视司法,甚至可以说,中国法律体系的构建只是法律规范体系的构建。但是,仅凭立法并不能创造出一个完善、有效的法律体系。因为立法不是万能的,不可能对现实生活中的所有涉法问题都给出明确的规范而不需要司

^⑨ 《马克思恩格斯选集》(第4卷),人民出版社1995年版,第702页。

法的裁量。”^⑩简而言之,面对千变万化的案件事实,法官不可能都可以从僵死的法律之中找到现成的答案。如何理解法律并根据不同案件事实情况给予恰当的裁判,是司法裁量的核心要义所在,这一过程,本质上就是“释法”过程。因此,从法律适用角度而言,变化的案件事实与固化的法律之间的矛盾必然导致“释法中心主义”而非“立法中心主义”。

综上所述,提倡“释法中心主义”取代“立法中心主义”是社会主义法律体系建成之后的必然要求,是对“立法万能主义”思维的摒弃。“立法中心主义”注重扩大总量,试图创设新法解决问题,而“释法中心主义”则注重盘活存量,力图用解释旧法处理案件。长期以来,只要出现所谓的“法律漏洞”时,人们习惯性的希望创设新法来进行处理。以创设新罪为主要特征的刑法历次修正正是“立法中心主义”或者“立法万能主义”的直接体现。需要指出的是,我们反对“立法中心主义”并非是反对任何形式的立法,因为社会的发展与变化使得创设新法仍然不可避免。反对“立法中心主义”主要在于反对过度频繁的造法,反对运动式、政绩式的造法。提倡“释法中心主义”本质上是法律克制主义的表现,是对法律有限性的理性把握和司法者能动性的积极倡导。可以预见,由“立法中心主义”迈向“释法中心主义”是未来一段时期内我国法治的基本趋势和主要特征。

Abstract: Various amendments of Criminal Law show that Chinese Criminal Law is changing from severity but no rigorousness to rigorousness but no severe. However, the target of Criminal Law amendment is strict net of justice. As different aspects in the strict Criminal Law, law explanation dose not repel law legislation, but it is definitely prior to the application of law legislation. The nature of law legislation of frequent crime is the embodiment of implemental thought of Criminal Law and functional generalization of Criminal Law, which should be vigilant or be restricted. Under the background of the basically established socialist legal system, the center will be transformed from law legislation to law explanation.

(责任编辑:白岫云)

^⑩ 刘茂林、王从峰:《论中国特色社会主义法律体系形成的标准》,载《法商研究》2010年第6期。